

《民事诉讼律师知识库》

职业培训课程 · 从入门到精通

第1章 民事诉讼基础理论

1.1 民事诉讼的基本概念与原则

【知识点讲解】

民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依法审理和解决民事纠纷的活动。民事诉讼律师作为当事人的诉讼代理人，必须深刻理解民事诉讼的基本框架。民事诉讼的基本原则包括：当事人诉讼权利平等原则、辩论原则、处分原则、诚实信用原则、法院调解原则等。这些原则贯穿诉讼全过程，是律师开展代理工作的根本遵循。

【操作步骤或工作流程】

1. 接受委托前，向当事人说明民事诉讼的基本流程和可能结果；
2. 评估案件是否属于民事诉讼受案范围；
3. 确认管辖法院，判断是否存在专属管辖或协议管辖；
4. 审查诉讼时效，判断是否超过法定期间；
5. 根据案件性质选择普通程序、简易程序或小额诉讼程序；
6. 制定整体诉讼策略，明确诉讼请求和事实依据。

【注意事项】

1. 注意区分民事诉讼与行政诉讼、刑事诉讼的界限，避免程序选择错误；
2. 诉讼时效为三年（一般情况），自权利人知道或应当知道权利受到损害之日起计算；
3. 某些案件适用特殊诉讼时效；
4. 法院调解贯穿诉讼全过程，但调解必须基于当事人自愿；
5. 不得虚构事实、伪造证据，否则将承担法律责任。

【常见问题】

Q：民事诉讼的受案范围包括哪些？A：包括合同纠纷、侵权纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、物权纠纷、知识产权纠纷、劳动争议等平等主体之间的财产关系和人身关系纠纷。

Q：当事人可以自行起诉而不委托律师吗？A：可以。但涉及复杂法律关系的案件，建议委托专业律师，以保障诉讼权利和实体权利。

【实际案例】

案例：甲公司与乙公司签订买卖合同，乙公司未按约付款。甲公司委托律师起诉。律师首先审查合同效力，确认管辖条款约定由原告所在地法院管辖；其次核查诉讼时效，确认未超过三年；最后确定诉讼请求为支付货款及逾期利息。法院受理后适用普通程序审理，最终判决支持甲公司全部诉讼请求。本案例体现了律师在诉前对管辖、时效、请求权基础的系统审查。

1.2 管辖制度与程序选择

【知识点讲解】

管辖制度是确定哪一级、哪一个法院受理案件的法律制度。正确确定管辖法院是诉讼成功的前提。管辖分为级别管辖和地域管辖。级别管辖根据案件标的额、案件性质和复杂程度确定由基层法院、中级法院、高级法院还是最高法院管辖。地域管辖一般实行原告就被告原则，但合同纠纷可由被告住所地或合同履行地法院管辖，侵权纠纷可由侵权行为地或被告住所地法院管辖。

【操作步骤或工作流程】

1. 确定案件类型，判断是否属于专属管辖（如不动产纠纷由不动产所在地法院管辖）；2. 如无专属管辖，查看是否存在有效的协议管辖条款；3. 确定级别管辖：查阅当地法院关于级别管辖的标的额标准；4. 确定地域管辖：根据案件性质选择被告住所地、合同履行地、侵权行为地等；5. 如存在管辖争议，可在答辩期内提出管辖权异议；6. 准备管辖相关证据材料（如被告住所地证明、合同履行地证明）。

【注意事项】

1. 协议管辖必须采用书面形式，且不得违反级别管辖和专属管辖规定；2. 管辖权异议应在提交答辩状期间提出（收到起诉状副本后15日内）；3. 对管辖权异议裁定不服的，可在10日内提起上诉；4. 互联网合同纠纷可由买受人住所地或被告住所地法院管辖；5. 多个被告住所地不在同一辖区的，各被告住所地法院均有管辖权。

【常见问题】

Q：合同未约定履行地点，如何确定合同履行地？A：给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。

Q：被告下落不明，应向哪个法院起诉？A：仍应向被告住所地法院起诉，法院可通过公告送达方式处理。如被告住所地无法确定，可依据具体案情确定管辖。

【实际案例】

案例：张某向李某借款50万元，双方未约定管辖法院。张某住所地在A市，李某住所地在B市，借款通过银行转账在C市完成。李某委托律师起诉要求还款。律师分析认为，本案为借款合同纠纷，被告住所地A市法院有管辖权；同时，接收货币一方李某所在地B市法院也有管辖权。律师选择向B市法院起诉。法院受理后，张某提出管辖权异议。法院审查后裁定驳回异议，理由是B市作为接收货币一方所在地属于合同履行地，依法享有管辖权。

第2章 案件受理与立案

2.1 起诉条件与立案审查

【知识点讲解】

起诉是民事诉讼程序的开始。根据《民事诉讼法》第一百二十二条，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。立案审查分为形式审查和实质审查，法院应在七日内决定是否立案。

【操作步骤或工作流程】

1. 与当事人充分沟通，了解案件基本事实和诉求；2. 审查原告主体资格，确认其与案件有直接利害关系；3. 确定被告身份信息，确保被告明确可识别；4. 梳理事实经过，提炼法律关系和请求权基础；5. 明确诉讼请求，做到具体、明确、可执行；6. 收集初步证据材料，制作证据清单；7. 撰写起诉状，核对当事人信息、诉讼请求、事实与理由；8. 准备身份证明材料、授权委托书、律师事务所函；9. 向有管辖权的法院提交立案材料；10. 跟踪立案进展，及时补充材料。

【注意事项】

1. 被告信息必须明确，至少应提供姓名或名称、住所地等基本信息；2. 诉讼请求应具体明确，例如要求被告支付货款人民币XX元及逾期利息（自X年X月X日起按LPR计算至实际付清之日止）；3. 事实与理由部分应简明扼要，突出关键事实和法律依据；4. 证据材料应按顺序编号并制作证据清单；5. 网上立案已成为主流方式，需熟悉各地法院的网上立案系统操作；6. 如法院裁定不予受理，可在10日内向上一级法院提起上诉。

【常见问题】

Q：没有被告身份证号可以立案吗？A：可以。有明确的被告不要求必须提供身份证号，但应提供足以使被告与他人相区别的信息，如姓名、性别、住所地、联系电话等。

Q：法院七日内未作出是否立案的决定怎么办？A：如法院既不立案又不作出不予受理裁定，当事人可以向上一级法院起诉，上一级法院认为符合起诉条件的，应当立案审理。

【实际案例】

案例：王某因交通事故受伤，欲起诉肇事司机赵某。王某委托律师后，律师发现王某仅知道赵某姓名和车牌号，无其他身份信息。律师首先向交警部门调取事故认定书，获取赵某的驾驶证信息；其次通过车辆登记信息查询赵某的住址；最后以赵某为被告向事故发生地法院提起诉讼。法院经审查认为被告明确，符合立案条件，予以立案。本案说明，律师应善于利用各种

渠道获取被告信息，确保满足明确的被告这一立案条件。

2.2 诉讼费用与保全申请

【知识点讲解】

诉讼费用包括案件受理费、申请费和其他诉讼费用。案件受理费按财产案件和非财产案件分别收取。财产案件根据诉讼请求的金额或价额按比例分段累计交纳。诉讼保全是指人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。

【操作步骤或工作流程】

1. 计算案件受理费：财产案件按标的额分段计算，非财产案件按件收取；2. 向当事人说明诉讼费用的预交规则和最终承担原则（一般由败诉方承担）；3. 评估是否需要申请财产保全：审查对方是否有转移财产的风险；4. 如需保全，准备保全申请书，列明保全财产的具体信息；5. 提供保全担保（可由保险公司出具保函）；6. 在起诉时或起诉后向法院提交保全申请；7. 如法院裁定保全，及时协助执行保全措施；8. 案件审结后，根据判决结果处理诉讼费用的分担和退还。

【注意事项】

1. 诉讼费用由原告预交，原告自接到法院交纳诉讼费用通知次日起7日内交纳；2. 申请保全的，应提供相当于请求保全数额的担保，但追索赡养费、扶养费、抚育费等案件除外；3. 保全错误造成被申请人损失的，申请人应承担赔偿责任；4. 诉前保全必须在法院采取保全措施后30日内起诉，否则保全解除；5. 诉讼费用可依法申请缓交、减交或免交，需符合法定条件。

【常见问题】

Q：诉讼费用由谁承担？A：一般由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，法院根据案件具体情况决定各自负担的数额。

Q：申请财产保全必须提供担保吗？A：原则上应当提供担保，但追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、劳动报酬等案件，以及因情况紧急不立即申请保全将使合法权益受到难以弥补的损害的其他案件，法院可以酌情处理。

【实际案例】

案例：甲公司起诉乙公司支付货款200万元。律师在诉前调查中发现，乙公司近期频繁转移资产，存在逃避债务的重大嫌疑。律师建议甲公司同时申请财产保全，冻结乙公司银行账户。甲公司委托保险公司出具了200万元的诉讼保全责任保险保函作为担保。法院审查后裁定冻结乙

公司名下银行存款200万元或查封、扣押同等价值的其他财产。执行保全后，乙公司账户被冻结，在诉讼过程中主动与甲公司达成调解协议，全额支付了货款。本案体现了财产保全在促进纠纷解决中的重要作用。

第3章 证据规则与证据收集

3.1 民事诉讼证据的种类与证明力

【知识点讲解】

民事诉讼证据是认定案件事实的根据。根据《民事诉讼法》及相关司法解释，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。证明力是指证据对案件事实的证明作用和价值。一般而言，国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力大于其他书证；物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言。

【操作步骤或工作流程】

1. 分析案件争议焦点，确定需要证明的事实；
2. 梳理当事人已掌握的证据材料，评估证据的完整性和证明力；
3. 对书证进行复印并核对原件，确保复印件与原件一致；
4. 对电子数据（如微信聊天记录、电子邮件）进行截图保存并进行公证保全；
5. 确定需要申请法院调取的证据（如银行流水、房产登记信息）；
6. 评估是否需要申请鉴定（如笔迹鉴定、工程造价鉴定、医疗损害鉴定）；
7. 制作证据清单，按证明目的分组编号；
8. 在举证期限内提交证据材料，逾期提交可能面临证据失权风险。

【注意事项】

1. 书证应当提交原件，物证应当提交原物，提交原件确有困难的可以提交复制品、照片、副本、节录本；
2. 电子数据应保存原始载体，必要时进行公证保全；
3. 证人应当出庭作证，接受双方当事人质询，无正当理由未出庭的证人证言不得作为认定案件事实的根据；
4. 鉴定意见存在缺陷的，可以申请补充鉴定或重新鉴定；
5. 举证期限由法院指定，一审普通程序不少于15日，二审不少于10日；
6. 对方当事人逾期提交证据的，律师应及时提出异议。

【常见问题】

Q：微信聊天记录可以作为证据使用吗？A：可以。微信聊天记录属于电子数据，可以作为证据使用。但应保存原始载体（手机），必要时进行公证，并证明聊天对方的身份。

Q：录音证据是否有效？A：录音属于视听资料，可以作为证据。但录音的取得方式必须合法，不得侵害他人合法权益或违反法律禁止性规定。偷偷录音在特定情况下可能被采纳，但需结合具体案情判断。

【实际案例】

案例：陈某起诉刘某归还借款10万元，仅有银行转账记录，无借条。刘某辩称该款项为投资款而非借款。陈某委托律师后，律师指导陈某补充收集证据：一是调取双方微信聊天记录，其中刘某多次表示会还钱；二是对微信聊天记录进行公证保全；三是申请陈某的妻子作为证人出庭作证，证明借款经过。庭审中，律师将银行转账记录、微信聊天记录、证人证言组合使用，形成完整的证据链。法院综合审查后认定借贷关系成立，判决刘某归还借款及利息。本案说明，在缺乏直接证据时，律师应善于组合多种证据形成证据链。

3.2 举证责任分配与证据交换

【知识点讲解】

举证责任是指当事人对自己提出的主张有责任提供证据加以证明。举证责任分配的一般原则是：谁主张，谁举证。即当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。在特定情形下实行举证责任倒置，如环境污染、医疗损害、高度危险作业等侵权纠纷中，由加害方就免责事由承担举证责任。证据交换是在法院主持下，双方当事人相互展示证据、了解对方证据材料的诉讼活动，有助于明确争议焦点、提高庭审效率。

【操作步骤或工作流程】

1. 明确己方需要证明的事实和对应的证据；
2. 分析对方的诉讼请求和可能提出的证据，预判对方的举证方向；
3. 对于己方无法取得的证据，及时申请法院调查收集；
4. 在举证期限内提交全部证据材料；
5. 参加法院组织的证据交换，仔细审查对方提交的证据；
6. 对对方证据的真实性、合法性、关联性发表质证意见；
7. 针对对方证据的瑕疵，准备反驳证据；
8. 庭审中围绕证据的三性（真实性、合法性、关联性）进行举证和质证。

【注意事项】

1. 主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证责任；
2. 主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证责任；
3. 自认的事实无需举证，但涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由法院依职权调查的事实除外；
4. 对于对方逾期提交的证据，应明确提出不予质证或不予采纳的意见；
5. 证人出庭前应进行必要的辅导，但不得诱导证人作伪证。

【常见问题】

Q：对方拒绝提供对其不利的证据怎么办？A：如该证据由对方当事人控制，可申请法院责令对方提交。对方无正当理由拒不提交的，法院可以认定申请人所主张的书证内容为真实。

Q：举证期限届满后还能补充提交证据吗？A：原则上应在举证期限内提交。但因客观原因逾期提供证据，或者对方当事人对逾期提供证据未提出异议的，视为未逾期。法院根据案件情况也可以酌情采纳逾期证据，但可能对逾期方予以训诫或罚款。

【实际案例】

案例：某消费者起诉某电商平台销售假冒伪劣商品，要求退一赔三。消费者主张商品为假货，但仅提供了购买记录 and 商品照片。电商平台辩称商品为正品，并提供了进货单据和品牌授权书。消费者律师分析认为，证明商品为假货的举证责任在消费者一方，现有证据不足。律师遂申请法院委托鉴定机构对商品真伪进行鉴定。鉴定结论确认商品为假冒注册商标的商品。法院据此判决支持消费者退一赔三的诉讼请求。本案体现了在举证困难时，律师应善于运用鉴定手段完成举证责任。

第4章 庭审准备与出庭技巧

4.1 庭前准备与庭审策略制定

【知识点讲解】

庭前准备是庭审成功的基础，充分的准备工作直接影响案件审理结果。庭前准备包括：熟悉案情和证据材料、研究相关法律法规和司法解释、检索类似案例和裁判规则、预测对方可能的抗辩观点和证据、制定庭审查问提纲和辩论提纲、准备代理词框架等。庭审策略应根据案件具体情况灵活制定，包括主攻方向、防御重点、调解底线等。

【操作步骤或工作流程】

1. 全面梳理案件事实，制作时间轴和事件经过表；
2. 整理全部证据材料，制作证据目录和证明目的说明；
3. 检索相关法律法规、司法解释和指导性案例；
4. 分析对方可能的答辩观点和证据，准备应对方案；
5. 制定庭审查问提纲，包括对己方证人和对方当事人的发问；
6. 撰写代理词初稿，明确法律适用和请求依据；
7. 与当事人进行庭前沟通，告知庭审流程和注意事项；
8. 准备庭审所需的全部材料原件和复印件；
9. 模拟庭审场景，进行庭前演练。

【注意事项】

1. 代理词应在开庭前或庭后及时提交，不宜在庭审中全文宣读，应提炼核心观点进行陈述；
2. 庭审查问应简明扼要，避免诱导性提问；
3. 对方证据的质证意见应围绕真实性、合法性、关联性展开；
4. 注意法庭纪律，尊重审判人员和对方当事人；
5. 调解方案应事先与当事人沟通并取得授权；
6. 庭审笔录应仔细核对，发现错误及时要求更正。

【常见问题】

Q：开庭时当事人必须出庭吗？A：离婚案件等涉及身份关系的案件，当事人本人原则上应当出庭。其他案件当事人可以委托律师全权代理，但律师应事先取得特别授权。

Q：庭审中可以补充提交证据吗？A：可以，但应在举证期限内提交。逾期提交的，需说明理由，由法院决定是否采纳。建议尽量在庭前完成证据交换和提交。

【实际案例】

案例：某建设工程合同纠纷案，原告起诉要求支付工程款800万元。被告反诉称工程质量不合格，要求赔偿损失300万元。原告律师在庭前做了充分准备：一是整理了全部施工日志、签证单、验收报告等证据；二是检索了同类案件的裁判规则，发现法院通常以竣工验收合格作为付款条件；三是预判被告可能主张的质量问题，准备了第三方检测报告作为反驳证据；四是制定

了详细的庭审发问提纲，针对被告反诉的证据薄弱环节设计了多个问题。庭审中，律师通过精准的发问和有利的质证，成功瓦解了被告的反诉主张。最终法院判决支持原告全部诉讼请求，驳回被告反诉。本案充分说明了庭前准备工作的重要性。

4.2 法庭辩论与最后陈述

【知识点讲解】

法庭辩论是庭审的核心环节，是双方当事人及其诉讼代理人就案件事实、证据和法律适用等问题进行辩论的诉讼活动。法庭辩论按照原告及其诉讼代理人发言、被告及其诉讼代理人答辩、第三人及其诉讼代理人发言或答辩、互相辩论的顺序进行。最后陈述是当事人在法庭辩论终结后所作的总结性发言，是当事人行使辩论权的最后机会。

【操作步骤或工作流程】

1. 法庭调查阶段结束后，审判长宣布进入法庭辩论阶段；
2. 第一轮辩论：发表主要辩论意见，围绕争议焦点展开论述；
3. 第二轮辩论：针对对方的辩论意见进行反驳和补充；
4. 辩论中适时引用证据和法律规定支持己方观点；
5. 控制发言时间，避免冗长重复；
6. 法庭辩论终结后，由审判长按照原告、被告、第三人的顺序征询各方最后陈述意见；
7. 最后陈述应简明扼要，重申核心诉求；
8. 如法庭组织调解，根据当事人授权参与调解协商。

【注意事项】

1. 辩论应围绕争议焦点进行，避免偏离主题或进行人身攻击；
2. 发言应条理清晰，可采用总-分-总的结构；
3. 对对方提出的新事实或新证据，应及时回应并提出异议；
4. 注意倾听对方发言，记录要点以便针对性反驳；
5. 最后陈述不是代理词的重复，而是当事人真实意愿的表达；
6. 如不同意调解或调解不成，应明确表态，等待法院判决。

【常见问题】

Q：法庭辩论中可以提出新的证据吗？A：一般应在法庭调查阶段出示证据。但在辩论中如发现新的事实需要证据证明，可申请恢复法庭调查，由法院决定是否准许。

Q：对方律师在辩论中使用不当言辞怎么办？A：可向审判长提出异议，要求对方遵守法庭纪律。切勿以同样方式回应，应保持专业素养。

【实际案例】

案例：某知识产权侵权纠纷案，原告主张被告侵犯其专利权。在法庭辩论阶段，被告律师突然提出原告专利属于现有技术，不构成侵权。原告律师立即申请恢复法庭调查，请求法院对现有技术抗辩进行审查。法院准许后，原告律师提交了专利审查档案和对比文件，证明其专利

具有新颖性和创造性。随后回到辩论阶段，原告律师围绕专利权的有效性、侵权比对的技术特征逐一展开论述，最终说服法院认定侵权成立。本案说明，律师在辩论中应灵活应对突发情况，善于申请恢复法庭调查以查明关键事实。

第5章 合同纠纷案件代理实务

5.1 合同效力审查与违约责任认定

【知识点讲解】

合同效力审查是合同纠纷案件代理的首要环节。合同效力分为有效、无效、可撤销和效力待定四种状态。有效合同应具备主体适格、意思表示真实、内容合法、形式合法等要件。无效合同包括：违反法律、行政法规的强制性规定；违背公序良俗；恶意串通损害他人合法权益等情形。违约责任是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时应承担的民事责任，主要包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。

【操作步骤或工作流程】

1. 审查合同主体资格：确认当事人是否具有相应的民事行为能力；
2. 审查合同订立过程：是否存在欺诈、胁迫、重大误解、显失公平等可撤销情形；
3. 审查合同内容：是否违反法律强制性规定或公序良俗；
4. 审查合同形式：法律法规规定应采用书面形式的，是否具备书面形式；
5. 分析违约事实：确定违约行为的具体表现和违约责任的承担方式；
6. 计算损失数额：包括直接损失和可得利益损失；
7. 审查违约金条款：判断违约金是否过高或过低，必要时申请调整；
8. 确定诉讼请求：根据案件情况选择主张继续履行、解除合同或赔偿损失。

【注意事项】

1. 注意区分效力性强制性规定和管理性强制性规定，只有违反效力性强制性规定的合同才无效；
2. 可撤销合同的撤销权应在知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使；
3. 违约金过高的，违约方可以请求法院适当减少，一般以实际损失的130%为上限参考；
4. 可得利益损失的计算应具有确定性，不能是纯粹假设性的利益；
5. 格式条款提供方应履行提示和说明义务，否则对方可主张该条款不成为合同内容。

【常见问题】

Q：合同未盖章但有法定代表人签字，合同是否有效？A：有效。法定代表人代表法人从事民事活动，其签字与盖章具有同等法律效力。但需注意签字人是否具有法定代表人身份。

Q：违约金和定金可以同时主张吗？A：不可以。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，不能同时主张。

【实际案例】

案例：甲公司与乙公司签订设备采购合同，约定乙公司向甲公司供应某型号设备10台，总价500万元，违约金为合同总价的20%。乙公司仅交付6台设备后停止供货。甲公司委托律师起诉，要求乙公司支付违约金100万元并赔偿因停工造成的损失200万元。律师审查后发现，合同

约定的违约金比例过高，且甲公司主张的停工损失缺乏充分证据证明。律师调整诉讼策略，以乙公司根本违约为由请求解除合同，主张已交付设备的价款返还和未交付设备的违约金，同时申请法院对违约金数额进行调整。法院最终判决解除合同，乙公司返还已付货款并支付违约金60万元（调整为实际损失的1.3倍）。本案说明，律师应根据证据情况灵活调整诉讼策略，避免提出无法支持的诉讼请求。

5.2 建设工程合同纠纷代理要点

【知识点讲解】

建设工程合同纠纷是合同纠纷中的特殊类型，具有标的额大、专业性强、法律关系复杂等特点。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程施工合同无效但工程经竣工验收合格的，承包人可以参照合同约定请求支付工程价款。实际施工人可以突破合同相对性，直接向发包人主张权利。建设工程价款优先受偿权是承包人的法定权利，但应在合理期限内行使。

【操作步骤或工作流程】

1. 审查合同效力：是否存在转包、违法分包、借用资质等导致合同无效的情形；
2. 审查工程价款：核对合同约定的计价方式、变更签证、索赔款项；
3. 审查工程质量：是否存在质量缺陷，是否经过竣工验收；
4. 审查工期延误：分析延误原因，区分发包人原因、承包人原因和不可抗力；
5. 评估是否需要工程造价鉴定：对争议较大的工程价款申请司法鉴定；
6. 审查优先受偿权：确认是否在法定期限内主张（自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不超过18个月）；
7. 准备施工日志、签证单、验收报告、结算资料等关键证据。

【注意事项】

1. 未取得建设工程规划许可证等规划审批手续的建设工程施工合同无效，但发包人在起诉前取得的除外；
2. 实际施工人起诉发包人时，法院可以追加转包人或违法分包人为第三人；
3. 工程质量保证金返还期限一般为缺陷责任期满后，最长不超过2年；
4. 建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，但不得对抗已支付全部或大部分购房款的商品房买受人；
5. 黑白合同（阴阳合同）中，以中标合同作为结算工程价款的依据。

【常见问题】

Q：没有资质的实际施工人签订的合同有效吗？A：无效。承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同无效。但工程经竣工验收合格的，可以参照合同约定请求支付工程价款。

Q：发包人拖延结算怎么办？A：如合同约定了结算期限，发包人逾期未结算的，承包人可以请求按照送审价结算。如未约定，承包人可起诉请求法院委托鉴定确定工程价款。

【实际案例】

案例：某建筑公司承包某房地产开发公司的住宅楼工程，合同价款3000万元。工程竣工验收合格后，房地产公司拖延结算，仅支付2000万元。建筑公司委托律师起诉。律师首先审查了合同、施工日志、签证单、竣工验收报告等证据；其次申请工程造价鉴定，确认工程总价款为3200万元（含变更签证200万元）；最后主张建设工程价款优先受偿权。法院经审理认为，建筑公司已完成施工且工程验收合格，房地产公司应支付剩余工程款1200万元。同时，建筑公司在法定期限内主张了优先受偿权，法院判决建筑公司就该住宅楼工程折价或拍卖的价款优先受偿。本案体现了律师在建设工程纠纷中应综合运用合同审查、造价鉴定和优先受偿权等多种手段维护当事人权益。

第6章 侵权纠纷案件代理实务

6.1 人身损害赔偿案件代理

【知识点讲解】

人身损害赔偿是指因侵权行为造成他人身体伤害或死亡而应承担的民事赔偿责任。赔偿范围包括：医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应赔偿丧葬费和死亡赔偿金。残疾赔偿金和死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准计算。

【操作步骤或工作流程】

1. 收集侵权事实证据：包括报警记录、现场照片、监控录像、证人证言等；
2. 收集损害后果证据：包括病历资料、医疗费票据、诊断证明、伤残鉴定报告等；
3. 确定赔偿项目：根据损害后果确定应主张的赔偿项目；
4. 计算赔偿数额：按照法定标准和当地统计数据计算各项赔偿金额；
5. 确定责任主体：分析侵权人、用人单位、安全保障义务人等可能的责任主体；
6. 评估责任比例：根据过错程度确定各方应承担的责任比例；
7. 如需要，申请伤残等级鉴定或因果关系鉴定；
8. 准备起诉材料，向有管辖权的法院提起诉讼。

【注意事项】

1. 人身损害赔偿的诉讼时效为三年，自权利人知道或应当知道权利受到损害之日起计算；
2. 伤残鉴定应在治疗终结后进行，一般在伤情稳定后3至6个月申请；
3. 被扶养人生活费的计算需考虑被扶养人的年龄、扶养人数和当地消费支出标准；
4. 精神损害抚慰金的数额由法院根据侵权情节、损害后果、当地生活水平等因素酌定；
5. 受害人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任；
6. 同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金。

【常见问题】

Q：农村户口的受害人能否按城镇标准计算残疾赔偿金？A：可以。受害人的经常居住地或主要收入来源地为城镇的，可以按照城镇居民标准计算残疾赔偿金和死亡赔偿金。

Q：后续治疗费可以一并主张吗？A：可以。根据医疗证明或鉴定结论确定必然发生的后续治疗费，可以与已经发生的医疗费一并赔偿。如无法确定，可待实际发生后另行起诉。

【实际案例】

案例：张某在某商场购物时，因地面湿滑摔倒，导致右腿骨折。张某委托律师起诉商场要求赔偿。律师首先调取了商场监控录像，证明张某摔倒时地面确实存在水渍；其次收集了张某的病历、医疗费票据（共计5万元）、诊断证明和伤残鉴定报告（十级伤残）；最后查询了当地

上一年度城镇居民人均可支配收入为5万元。律师计算赔偿数额：医疗费5万元、误工费2万元、护理费1万元、营养费3000元、残疾赔偿金10万元（5万乘20年乘10%）、精神损害抚慰金5000元，合计18.8万元。法院经审理认为，商场作为经营场所的管理人，未尽到安全保障义务，应承担主要责任（70%）；张某自身未尽到注意义务，承担次要责任（30%）。最终判决商场赔偿张某13.16万元。本案体现了律师在人身损害赔偿案件中应全面收集证据、准确计算赔偿数额、合理分析责任比例。

6.2 交通事故责任纠纷处理

【知识点讲解】

交通事故责任纠纷是指机动车发生交通事故造成人身伤亡或财产损失而引发的民事赔偿纠纷。处理交通事故责任纠纷应遵循以下顺序：首先由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；仍有不足的，由侵权人赔偿。交通事故责任认定书是确定责任比例的重要依据，但并非唯一依据，法院可以结合案件实际情况对责任比例进行调整。

【操作步骤或工作流程】

1. 事故发生后，指导当事人及时报警并保护现场；
2. 协助当事人收集证据：事故认定书、现场照片、医疗记录、车辆维修发票等；
3. 查询肇事车辆的保险情况：交强险和商业三者险的承保公司及保额；
4. 评估损害后果：人身损害需进行伤残鉴定，财产损失需进行评估；
5. 确定被告：包括肇事司机、车辆所有人、保险公司等；
6. 计算赔偿数额：在交强险限额内不区分责任比例，超出部分按责任比例分担；
7. 优先与保险公司协商理赔，协商不成再起诉；
8. 起诉时将保险公司列为共同被告，便于一次性解决赔偿问题。

【注意事项】

1. 交强险死亡伤残赔偿限额为18万元，医疗费用赔偿限额为1.8万元，财产损失赔偿限额为2000元；
2. 肇事司机逃逸的，保险公司在交强险范围内仍应赔偿，但商业三者险可能免赔；
3. 机动车所有人与使用人不一致时，原则上由使用人承担责任，所有人有过错的承担相应责任；
4. 非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的责任；
5. 交通事故认定书不服的，可在收到认定书之日起3日内申请复核。

【常见问题】

Q：交通事故中对方全责但无保险，怎么办？A：可起诉肇事司机和车辆所有人要求赔偿。如对方确实无力赔偿，可申请法院执行其财产。同时，如己方车辆投保了车损险，可向己方保险公司申请代位求偿。

Q：交通事故中的车辆贬值损失可以主张吗？A：一般不予支持。对于车辆贬值损失，法院通常认为不属于交通事故财产损失的赔偿范围，但极少数特殊情况下可能酌情支持。

【实际案例】

案例：李某驾驶小轿车与王某驾驶的电动自行车发生碰撞，造成王某受伤、两车损坏。交警部门认定李某负主要责任，王某负次要责任。王某委托律师处理赔偿事宜。律师首先指导王某进行了伤残鉴定，鉴定结果为九级伤残；其次查询了李某车辆的保险情况，确认交强险和商业三者险（保额100万元）均由某保险公司承保；然后计算赔偿总额：医疗费8万元、误工费3万元、护理费1.5万元、残疾赔偿金20万元、精神损害抚慰金1万元、财产损失2000元，合计33.7万元。律师将李某和保险公司一并起诉。法院审理后判决：保险公司在交强险限额内赔偿19.8万元（医疗费1.8万+伤残18万），在商业三者险范围内按70%比例赔偿剩余13.9万元中的9.73万元，合计29.53万元。王某自行承担剩余部分。本案说明，律师应善于利用保险机制，将保险公司列为被告，确保赔偿能够得到实际履行。

第7章 婚姻家庭案件代理实务

7.1 离婚诉讼中的财产分割

【知识点讲解】

离婚诉讼中的财产分割是婚姻家庭案件的核心争议之一。夫妻共同财产包括婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、劳务报酬；生产、经营、投资的收益；知识产权的收益；继承或受赠的财产（遗嘱或赠与合同中确定只归一方的除外）等。夫妻对共同财产有平等的处理权。离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产的，在分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或不分。

【操作步骤或工作流程】

1. 全面梳理夫妻共同财产：包括房产、车辆、存款、股票、基金、股权、债权等；
2. 收集财产证据：房产证、车辆登记证、银行流水、股票账户信息、公司工商登记等；
3. 区分夫妻共同财产与个人财产：婚前财产、一方因受到人身损害获得的赔偿或补偿等属于个人财产；
4. 调查对方是否存在隐藏、转移财产的行为：通过银行流水、交易记录等进行分析；
5. 评估财产价值：对房产、股权等需要评估的财产申请司法鉴定；
6. 确定分割方案：实物分割、变价分割或作价补偿；
7. 如对方存在过错（如重婚、家暴、虐待等），主张多分财产或损害赔偿；
8. 准备起诉材料或应诉材料，参加庭审。

【注意事项】

1. 夫妻一方个人财产在婚后产生的收益，除孳息和自然增值外，应认定为夫妻共同财产；
2. 婚后由一方父母出资为子女购买的不动产，产权登记在出资人子女名下的，视为只对自己子女一方的赠与，属于个人财产；
3. 离婚时一方尚未取得经济利益的知识产权，归一方所有，在分割夫妻共同财产时，可根据具体情况对另一方予以适当照顾；
4. 夫妻一方隐藏、转移财产的，另一方发现后可自发现之日起三年内请求再次分割；
5. 离婚协议中关于财产分割的条款对双方具有法律约束力，但存在欺诈、胁迫情形的可以撤销。

【常见问题】

Q：婚前购买的房产，婚后共同还贷，离婚时如何分割？A：该房产归产权登记一方所有，尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，由产权登记一方对另一方进行补偿。

Q：对方在离婚前将存款转给他人怎么办？A：可申请法院调查对方银行流水，如证实存在转移财产的行为，在分割财产时对该方可以少分或不分。同时可请求法院责令对方说明资金去向。

【实际案例】

案例：赵某与钱某结婚10年，育有一子。赵某起诉离婚并要求分割夫妻共同财产。钱某委托律师应诉。律师首先指导钱某梳理夫妻共同财产：婚后购买的房产一套（价值300万元，尚有贷款80万元）、车辆一辆（价值15万元）、银行存款50万元、股票账户市值30万元。其次，律师通过申请法院调查令，调取了赵某近两年的银行流水，发现赵某在起诉前半年内分多次向一个陌生账户转账共计60万元。律师主张该60万元属于转移的夫妻共同财产，应作为共同财产进行分割，且赵某存在转移财产的行为，在分割时应少分。法院经审理认为，赵某无法说明该60万元的合理去向，认定为转移夫妻共同财产。最终判决：房产归钱某所有，钱某补偿赵某相应份额；车辆归赵某所有；银行存款、股票及被转移的60万元作为共同财产分割，赵某因转移财产少分20%。本案说明，律师应善于运用调查手段查明对方隐藏的财产，维护当事人合法权益。

7.2 抚养权与探望权纠纷处理

【知识点讲解】

离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。抚养费的数额，可以根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。有固定收入的，抚养费一般可以按其月总收入的20%至30%的比例给付。负担两个以上子女抚养费的，比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的50%。不直接抚养子女的父或母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。

【操作步骤或工作流程】

1. 了解子女的基本情况：年龄、健康状况、学习情况、生活习惯等；2. 评估双方的抚养条件：经济收入、居住环境、教育背景、与子女的感情等；3. 收集有利于争取抚养权的证据：与子女共同生活的照片、视频，子女的学校证明，自身的收入证明和居住证明等；4. 如子女已满八周岁，了解并尊重子女的意愿，必要时申请法院单独询问子女；5. 计算抚养费数额：根据对方收入情况和子女实际需要确定；6. 确定探望权的行使方式：探望时间、地点、频率等；7. 如对方拒不履行探望权，可申请法院强制执行或起诉变更抚养权；8. 随着子女成长和情况变化，可起诉要求变更抚养权或调整抚养费数额。

【注意事项】

1. 抚养权的判决以子女利益最大化为原则，不是简单的经济条件比拼；2. 一方有赌博、吸毒、家暴等恶习的，一般不宜获得抚养权；3. 抚养费可以定期给付，也可以一次性给付，但一次性给付需考虑对方的支付能力；4. 探望权的行使不得影响子女的正常生活和学习；5. 如直接抚养方存在不利于子女身心健康的情形，另一方可以起诉要求变更抚养权；6. 抚养费可以根据子女实际需要、父母负担能力和当地生活水平的变化而调整。

【常见问题】

Q：对方不支付抚养费怎么办？A：如通过法院判决或调解确定的抚养费，对方拒不支付的，可申请法院强制执行。如通过离婚协议约定的抚养费，需先起诉要求对方履行协议。

Q：探望权可以强制执行吗？A：可以。对拒不协助另一方行使探望权的有关个人或单位，法院可以依法采取拘留、罚款等强制措施，但不能对子女的人身进行强制执行。

【实际案例】

案例：孙某与周某离婚，双方均要求抚养5岁的女儿小孙。孙某（女方）委托律师争取抚养权。律师首先收集了孙某的收入证明（月薪1.5万元）、房产证（自有住房）、小孙的幼儿园证明（一直由孙某接送）等证据；其次，律师了解到周某工作繁忙，经常出差，平时很少陪伴女儿；再次，律师申请法院对小孙进行心理评估，评估报告显示小孙与母亲感情深厚，改变生活环境可能对其心理造成不利影响。庭审中，律师强调孙某有稳定的经济来源和良好的居住环境，且小孙一直由孙某照顾，改变抚养人不利于子女成长。法院最终判决小孙由孙某直接抚养，周某每月支付抚养费4000元，每周探望一次。本案说明，律师在抚养权纠纷中应围绕子女利益最大化原则，从经济条件、生活环境、情感联系等多方面举证。

第8章 执行程序与强制执行

8.1 执行申请与财产调查

【知识点讲解】

执行程序是实现生效法律文书确定的权利义务的程序。发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。执行立案后，法院应当向被执行人发出执行通知，并可以立即采取强制执行措施。财产调查是执行程序的关键环节，法院通过网络执行查控系统对被执行人的银行存款、车辆、房产、证券等财产信息进行查询。

【操作步骤或工作流程】

1. 确认法律文书已生效：一审判决需过上诉期，二审判决作出即生效；
2. 确认履行期限已届满：法律文书规定了履行期限的，需等待期限届满；
3. 准备执行申请材料：申请执行书、生效法律文书副本、身份证明、委托手续等；
4. 向一审法院或与一审法院同级的被执行财产所在地法院申请执行；
5. 提供被执行人的财产线索：银行账户、房产地址、车辆信息、股权信息等；
6. 跟踪法院执行进展：定期联系执行法官了解查控情况；
7. 如法院查控到财产，协助办理查封、扣押、冻结手续；
8. 如被执行人拒不履行，申请将其纳入失信被执行人名单和限制高消费；
9. 如法院穷尽执行措施仍未发现可供执行财产，案件可能终结本次执行程序，但发现财产后可申请恢复执行。

【注意事项】

1. 申请执行必须在法定期限内提出，超过二年可能丧失申请执行权；
2. 执行费用由被执行人承担，申请人无需预交；
3. 法院依职权查控的财产范围有限，律师应积极提供财产线索；
4. 被执行人转移、隐匿财产的，可申请法院采取搜查措施或追究其拒不执行判决、裁定罪的刑事责任；
5. 多个债权人对同一被执行人申请执行的，按照执行法院采取执行措施的先后顺序受偿（优先债权除外）；
6. 执行和解协议达成后，如被执行人不履行，可申请恢复执行原生效法律文书。

【常见问题】

Q：对方没有财产可供执行怎么办？A：如法院穷尽执行措施未发现可供执行财产，案件将终结本次执行程序。但终结本次执行程序后发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，且不受申请执行时效期间的限制。

Q：可以申请执行对方的养老金吗？A：可以。被执行人的养老金属于其责任财产的范围，法院可以冻结、扣划，但应预留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。

【实际案例】

案例：甲公司诉乙公司支付货款100万元胜诉，但乙公司拒不履行。甲公司委托律师申请强制执行。律师首先查询了乙公司的工商登记信息，发现乙公司仍在正常经营；其次，通过申请法院调查令，调取了乙公司的银行账户流水，发现乙公司在判决生效后将大量资金转移至其关联公司丙公司；再次，律师申请法院对乙公司的法定代表人采取限制高消费措施，并将其纳入失信被执行人名单；最后，律师建议甲公司追究乙公司拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。在强大的执行压力下，乙公司主动与甲公司达成执行和解协议，分期支付了全部货款。本案说明，律师在执行阶段应主动调查财产线索，综合运用多种执行措施，迫使被执行人履行义务。

8.2 执行异议与执行和解

【知识点讲解】

执行异议是指在执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议，主张对该标的享有足以排除强制执行的权益。案外人提出执行异议后，法院应在十五日内审查。理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服的，可以提起执行异议之诉。执行和解是指在执行过程中，双方当事人自愿协商达成协议，变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。执行和解协议达成后，法院可以裁定中止执行或终结执行。

【操作步骤或工作流程】

1. 作为申请执行人：如案外人对执行标的提出异议，审查异议理由是否成立，准备反驳意见和证据；2. 作为案外人：如认为执行标的属于自己所有，在执行过程中及时向执行法院提出书面异议，并提交权属证明；3. 对执行异议裁定不服的，在法定期限内提起执行异议之诉（案外人异议之诉或申请执行人异议之诉）；4.

作为被执行人：如认为执行行为违法，可以向负责执行的法院提出书面异议；5.

评估执行和解的可行性：分析被执行人的履行能力和诚信状况；6.

起草执行和解协议：明确履行标的、期限、方式、违约责任等；7.

如被执行人不履行和解协议，及时申请恢复执行原生效法律文书；8.

如和解协议已履行完毕，申请法院作执行结案处理。

【注意事项】

1. 案外人提出执行异议应在执行标的执行终结前提出，执行标的由当事人受让的，应在执行程序终结前提出；2. 执行异议之诉的审理期间，法院不得对执行标的进行处分；3. 申请执行人执行异议之诉中，案外人应就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证责任；4. 执行和解协议一般应采用书面形式，口头和解应记入笔录；5. 被执行人不履行和解协议的，申请执行人可以选择申请恢复执行原生效法律文书，也可以就履行和解协议提起诉讼（二者择一）；6.

执行和解协议中约定的担保条款，在被执行人不履行时可以直接执行担保财产或担保人财产。

【常见问题】

Q：执行和解协议可以约定违约金吗？A：可以。执行和解协议是当事人自愿达成的协议，可以约定违约金条款。如被执行人不履行和解协议，申请执行人恢复执行时，可以主张违约金，但违约金和迟延履行期间的债务利息一般不能同时主张。

Q：执行异议被驳回后还能怎么办？A：如案外人异议被驳回，案外人可以自裁定送达之日起十五日内提起案外人执行异议之诉。如申请执行人异议被驳回，申请执行人可以自裁定送达之日起十五日内提起申请执行人执行异议之诉。

【实际案例】

案例：某银行申请法院执行借款人王某的房产。在执行过程中，案外人李某提出执行异议，称该房产系其向王某购买，已支付全部房款并实际占有使用，仅因王某拖延未办理过户登记。李某委托律师代理执行异议。律师首先指导李某准备了房屋买卖合同、付款凭证、物业费缴纳记录、水电费缴纳记录等证据；其次，律师检索了相关案例，发现司法实践中对于已支付全部价款并实际占有的买受人，一般支持其排除执行的请求。法院经审查认为，李某在法院查封前已与王某签订合法有效的买卖合同，支付了全部价款并实际占有该房产，未办理过户登记非因李某自身原因，李某对该房产享有足以排除强制执行的民事权益。法院裁定中止对该房产的执行。银行不服提起申请执行人异议之诉，一审、二审均败诉。本案说明，律师在代理执行异议案件时，应准确把握案外人排除执行的法定要件，全面收集和整理证据。